独占禁止法上の単独行為規制のあり方について

台湾/日本経済法会議
2025年12月26日、於京都大学
土田和博（早稲田大学名誉教授）

※本報告資料は、公正取引委員会・競争政策センターの「2030研究会」用に準備したPPT（2025年11月28日付）に修正を加えたものであることを付記します。

課　題

- 2030年の時点で、独占禁止法の単独行為（私的独占、不公正な取引方法）規制は、どのようなものであるべきか。
- そのためには、いかなる改正等が必要か。

なぜ単独行為規制か？

- 単独行為規制の停滞
- デジタル分野への適用の困難
  - 新しい行為の出現（自己優遇、後追い販売、platform envelopmentなど）
  - 二面（多面）市場
  - 無料サービス
  - 新しい正当化事由（サイバーセキュリティ、プライバシー等）

単独行為規制

- 私的独占（2条5項、3条後段）
  - 排除型
  - 支配型
- 不公正な取引方法（2条9項5号、6号、19条）
  - 自由競争減殺（共同ボイコット、差別対価、不当廉売、再販、抱合せ販売、取引妨害など）
  - 不公正な競争手段（抱合せ販売、取引妨害、8項、9項）
  - 取引上の優越的地位濫用（2条9項5号）

本日の話の構成

- 単独行為規制の現状とその原因
- IT分野・公益事業分野
- 課徴金制度
- 要件解釈上の疑義
- 効果要件の立証をめぐる問題
  - 不公正な取引方法規制の差止請求（独禁法24条）
  - 効果ベースアプローチの見直しと新しいform-based approach？

単独行為規制の現状

- 私的独占については、問題の所在、対応の要否を検討するデータが乏しい。
  - これに検討する上でも参考になると思われる独占的状態の定期的な調査（市場構造要件(国内総供給価額要件と事業分野占拠率要件)に該当すると認められる事業分野に関する調査）は、2018年に取り止められた。
  - 最後の定期調査では、国内総供給価額が９５０億円を超え，かつ，上位１社の事業分野占拠率が４５％を超え又は上位２社の事業分野占拠率の合計が７０％を超える事業分野（「今後の経済状況の変化によっては」2条7項の要件に該当することとなると認められるものを含む）は、ビール、ウィスキー、紙巻きたばこ、CPU、二輪自動車、ブロードバンドサービス、移動電気通信、国内定期航空旅客運送、宅配便運送、音楽著作権管理など２９分野あった。

単独行為規制の現状

- 私的独占に対する公正取引委員会の法的措置（排除措置命令、課徴金納付命令、確約計画認定）をみると、2008年度から2023年度迄で4件にとどまる。
- 同じ期間に欧州委員会は27件の102条（82条）に係る決定を発出したとされる（第一審裁判所・一般裁判所と欧州司法裁判所を合わせた判決は32件（L. McCallum et al., 2023））。

単独行為規制の現状

- 不公正な取引方法に対する公取委の法的措置は、2000年度から2024年度までで合計84件。年平均3件強。
- 次頁の表によれば、2012年度から2018年度まで0～2件程度までであったが、確約計画認定制度が導入された2019年度以降、3～7件まで増加している。ただし、2004年度8件、2003年度7件という年度もあったことを考えると、法的措置の件数は確約制度の導入によって劇的に増えたとまではいえない。
- 行為類型別では、優越的地位濫用が多く、排他条件付き取引・拘束条件付き取引、再販、取引妨害と続き、この4類型だけで、法的措置が取られた全件中、88%以上を占める。
- もっとも、警告、注意が行われたケースは、表には含まれていない。特に不当廉売の注意の件数はケタ違いに多い。優越的地位濫用も、タスクホースによる警告、注意が行われているほか、下請法（取適法）による勧告、指導も多く行われている。一般指定8項、9項は景品表示法により補完されており、むしろ同法による事件処理が原則となっている。

	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
再販	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	12
11項12項	3	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	3	2	21
取引妨害	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	12
優越	0	0	0	2	5	2	2	0	4	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	29
その他	1	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	10
合計	6	2	3	7	8	2	4	3	5	4	2	5	0	1	2	0	2	1	1	3	6	2	3	5	7	84

・各年度の公正取引委員会年次報告による。
・11項、12項＝排他条件付き取引、その他の拘束条件付き取引。
・青地の部分＝確約計画認定制度の導入以降の年度。

不公正な取引方法に係る差止請求事件数（24条）

年度	2001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	合計
件数	1	2	0	2	8	5	2	4	2	3	6	8	4	4	4	1	5	3	1	1	3	4	1	2	76

・公取委年次報告による。2001年度は記載がないが、公取委審決集で補った。脱漏等がありうるので、暫定バージョン。
・途中で年次報告の差止請求訴訟の報告方法が変更になったため、2002年度から2021度までは訴訟が確定（取下げを含む）した年度に、2022年度以降は訴訟が提起された年度に件数を割り当てている。
・上訴され上級審で判決が出ても、同一事件は1件と数える。

単独行為規制の現状・小括

- 公正取引委員会が事件として取り上げた私的独占、不公正な取引方法（法的措置）の件数は少ない。
- これは3条違反、19条違反の行為が少ないという理由によるものとは考えにくい。そうであれば、公取委の法執行、運用は抑制されている、停滞していると言わざるを得ないのではないか。
- 民事救済、特に24条訴訟が公取委の法執行を事実上、補完しているとも言い難い。
- そうすると、私的独占、不公正な取引方法の規制は、いずれも何からの対応が必要ということになる。

単独行為規制の停滞の原因？

Ⅰ　電力、ガス、電気通信、航空等の規制産業では、所管官庁を意識して独禁法適用を躊躇しているのではないか（栗田、2017年）

Ⅱ　非裁量型課徴金制度の導入とそれに伴う要件解釈の厳格化（同上）。

Ⅲ　私的独占の排除行為（2条5項）、不公正な取引方法の各行為類型の要件解釈に疑義が多い。

Ⅳ　特に効果要件の立証が困難（とりわけ自由競争減殺型の24条訴訟においてそうであるが、公取委にとっても同様か）。

IT分野、公益事業分野
（2003年報告書）

独占禁止法研究会報告書（2003年）

- 公取委が規制産業やIT分野のドミナントな事業者に私的独占や不公正な取引方法の規定を適用した事例は少ない。あるとしても警告等。NTT東日本（最判、2010年）は例外。
- これに関連して、2003年の独占禁止法研究会報告書は、不可欠施設を有する事業者を対象とした次のような法改正を提案したが（公正取引特報、2003）、頓挫した。

独占禁止法研究会報告書（2003年）

- （1）電気、ガス、電気通信、航空等の公益事業分野の不可欠施設等の専有に伴う問題（利用市場における競争者の排除）と、（2）ネットワーク効果による事実上の標準（パソコンのOS等）の問題（競争者の応用ソフトの排除など）が取り上げられた。
- 「不可欠施設」：①自然独占性、ネットワーク外部性、②必要不可欠性、③対抗施設構築の困難さが基本的要件であるが、④（競争者に利用させることによる）長期的な競争への影響や利用市場の規模の大小も考慮することとされた。
- 措置：利用拒否、差別、取引上の制限・義務づけ、競争者への顧客の移動を阻止・妨害する行為の差止めが原則。ただし、追加的に使用条件の情報公開、不可欠施設保有部門と利用サービス提供部門の情報遮断、内部補助禁止等も命じることができるとされていた。

独占禁止法研究会報告書（2003年）

- この報告書に対しては、現行の独禁法で十分対応できる、不可欠施設の規制は事業法によるべき、不可欠施設や参入阻止行為の定義が曖昧、この規制は投資インセンティブを抑制する、命令には事業法を所管する主務大臣との協議が義務づけられると使い勝手が悪い、独占的状態の定義に近づいてしまい、これに対する措置と区別できない等の理由で、改正法案は見送られたとされる。
- しかし、①「排除」、「支配」（2条5項）が一般的、包括的すぎ、かえって使いずらいことはデジタル分野の事前規制立法が物語っている、②少なくとも事業法の存在しない分野はある（IT、デジタル分野など）、③事業法がある場合でも、発動されないか、措置が不十分な場合には、公取委が対応する必要があるのではないか。

裁量型課徴金制度

裁量型課徴金制度

- 日本では、裁量的なペナルティやサンクションは裁判所のみが賦課することができる、あるいは裁量的課徴金と刑事罰が併科されると憲法39条（二重処罰の禁止）に違反するといった議論がある。
- しかし、この議論は、以下の②や③の意味での裁量的な課徴金については、克服されてきた。
- 裁量性の意味：①ある事件において違反を認定しても課徴金を課さないとすることができること（排除措置命令のみ）、②ある事件で複数の違反行為者が存在する場合、一部の事業者には課徴金を免除、減額し、他の事業者には全額または割増課徴金を課すことができること、③加重、軽減事由が存在する場合、どの程度、加算、減算するかを公取委が決定することができること。
- ②、③はリニエンシー制度、調査協力減算制度、加算制度などにより、ある程度実現してきている。

裁量型課徴金制度

- 問題は①。公認会計士法や薬機法（医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）に既に存在する「課徴金の納付を命じないことができる」とする規定を参考に、命令しない場合を独禁法にも明示的に規定し、徐々に拡大するという方向が考えられるのではないか。
- 公認会計士法：故意の虚偽証明に対して一定の行政処分がなされている場合であって、財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合（31条の２第2項1号）。
- 薬機法：業務改善命令等をする場合であって、保健衛生上の危害の発生、拡大に与える影響が軽微であると認められるとき、または許可の取消し、業務停止、登録の取消しを命じる場合（75条の２第1項1号、2号）（土田、2022）。

要件解釈上の問題

要件解釈上の疑義

- 思い付くままに挙げるだけでも、
  - 私的独占（2条5項）の「排除」（正常な競争行為との区別の基準、不定形の行為の範囲）
  - 自由競争減殺型の不公正な取引方法は市場画定を要するか（不要論として、和久井・2025）
  - 共同ボイコットや再販は原則違法か（原則違法の意味）
  - 差別対価は原価割れが要件となるか
  - 一般指定6項の「低い対価」の意義
  - 優越的地位濫用の排除措置（20条）として返金が含まれるか
- しかし、これらについては裁判所や公取委が一定の判断を行ったこともあり、公取委が私的独占や不公正な取引方法を取り上げる上で、重大な障害となるものではないはず。
- 多少あるとすれば、問題は、効果要件か。

効果要件の立証をめぐる問題（私人）

- 私人による差止請求訴訟（24条）では、自由競争減殺の立証の困難を回避するためか、取引妨害、優越的地位濫用であると主張する訴えが多い（ただし、単独の取引拒絶、不当廉売、共同ボイコットなどに関する訴えもある）。
- 24条訴訟では取引妨害に係る神鉄タクシー事件大阪高判（2014年）だけしか原告の差止請求が最終的に認容された例はない（平成29.5.9の被告による請求認諾のケースを除く）。
- 濫訴気味の事件も多いが（Vande Walle, 2025）、そうでないケースもある。濫訴とは思われない事件では、原告は不公正な取引方法の存在そのものの立証に失敗している（「著しい損害」以前に）。これは、特に自由競争減殺型において、市場画定や、画定された市場における競争に被告の行為が与える影響を立証することが極めて困難であることを物語っているのではないか。

差止請求制度（24条）に関する改正

- したがって、立証責任分配の方法が検討に値する。
- 少なくとも「正当な理由がないのに」と効果要件が規定されている類型（共同ボイコット（法定類型、指定類型）、総供給費用を著しく下回る不当廉売、再販）については、原告が行為要件を立証すれば、被告が正当化事由を含めて「公正な競争を阻害するおそれ」がないことを立証しなければ、不公正な取引方法が存在すると認めるもの（控え目な提案？）。

差止請求制度（24条）に関する改正

- 「著しい損害」の削除：差止請求制度の存在する特許法、著作権法、不正競争防止法にはない、この要件は削除する。
- 差止請求の範囲：被害者の個人的権利・利益の保護のための制度だと24条を理解しても、例えば再販の場合、ある消費者が通常購入する小売店に対する差止を許すだけではなく、ブランド内の小売店全体に対する拘束を差し止めないと意味がないから（そうしないと、通常購入する小売店は周辺の小売店より多少安く販売するだけ）、これを確認する文言が必要ではないか。
- 差止請求の内容：作為命令が可能であることを確認する文言を追加する。
- 公取委の意見提出に係る79条1項、2項（1項・食ベログ1件のみか）、当事者への書類提出命令に関する80条各項は、実際が分からないが、検討を要する可能性あり。

差止請求制度（24条）に関する改正

- 団体訴訟制度の独禁法への導入（不公正な取引方法に対する差止請求権は、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法による差止請求権と重複しない）。
- 適格消費者団体と「適格事業者団体」に訴権を認める（後者は、相手方と取引継続中の被害事業者が主張することが、通常、著しく困難な優越的地位濫用など）。
- 団体固有権構成（以上、土田・2022）

ADR

- 24条と関連制度の強化改正と並んで、あるいはそれ以上に有効と考えられるのは、行政機関が設置・運営するADRその他のあっせん、調停制度。
- 韓国の公正取引調停院は、2007年に不公正な取引方法に関する事業者間の紛争について調停を行う機関として設立され、2015年までに87%の事案で調停が成立しているとされる（裵、2017）。対象事案は優越的地位濫用のケースが多い。
- このように有効に機能しているのは、調停不調の場合には、公正去来委員会（KFTC）が審査手続を開始するとされることが一因と思われる（公的執行との連動）。
- 日本の場合、不調案件の全部を公取委が審査することは現実的でないであろうが、日本版紛争調停院が設立された場合には、少なくとも調停開始が決定されたにもかかわらず、一方当事者が欠席する場合には、何らかの不利益を課されることとすべきではないか。

効果要件の立証をめぐる問題（公取委）

- 公取委は、ソーシャルゲームに関するDeNA事件（2011年）で、市場画定や競争に及ぼす影響が問題となる自由競争減殺型の11項ではなく、競争手段の不公正さに（も）公正競争阻害性が求められる14項で事件処理をした。
- 第一興商事件（14項、2009年）、シスメックス確約（10項、2025年）も、（自由競争減殺型だけでなく）不公正な競争手段型の側面を併せ持つ行為と把握しているように思われる。
- 要するに、自由競争減殺型の不公正な取引方法は、効果要件を立証する上で、他の2類型に比べて、公取委においても困難を伴うことを示しているのではないか。

効果重視アプローチ

- 日本では、かつて極めて形式主義的に公正競争阻害性が判断されていた時代があった。例：併売店を専売店化したことを以て、公正競争阻害性を含む要件を充足するとした、森永乳業事件（同意審決・1954年）、大正製薬事件（勧告審決・1955年）。
- その後、東京精米機事件東京高判（1984年）の頃から、市場競争に及ぼす影響を重視した判断に変化していった。もっとも、不公正な取引方法（自由競争減殺型）については、この時点では市場画定や競争への悪影響の評価は必ずしも行われなかったとされる（平林、2009）

効果重視アプローチ

- 台湾公平交易法の「現代化」提言（黄銘傑、2017）
- 「対市場効果の分析を回避する法執行方式」が「現代化」を阻害
  - 独占的地位の濫用
  - カルテル
  - 垂直的制限

効果重視アプローチの見直し

- EUでも市場支配的地位濫用について、それ以前の形式主義的アプローチから、経済分析を重視し、効果ベースアプローチ（effects-based approach）に変更した欧州委員会の「2008年82条優先執行ガイダンス」があった。
- 2023年になって、欧州委員会は、経済学的な市場効果の分析に傾斜しすぎた同ガイダンスを修正する提案を行うとともに、修正されたアプローチに基づくガイドライン案を新たに提案している。
  - anticompetitive foreclosure -「profitably increase prices」の削除
  - as-efficient competitorsに関する記述の修正
  - AECテストの「格下げ」など

効果重視アプローチの見直し

- 同じ方向は、「事前規制（ex-ante regulation）」といわれるデジタル市場法（DMA）にも看取される。
- コアプラットフォームサービスの指定によって、102条の下で要求される市場画定を不要とし、ゲートキーパーの指定によって支配的地位を有する事業者の認定を不要とした（Schweitzer, 2021）。
- 同時に、5条、6条、7条に、（TFEU102条より）具体的に特定された違反行為を定めることにより、102条の濫用行為の同定を不要とした。

効果重視アプローチの見直し

- 日本でも、独禁法の曖昧な要件を補完立法により明確にした例として、下請法（1956年）がある。
- 同法は、対象となる優越的地位を有する親事業者（委託事業者）を資本金と（2026年1月以降は）従業員規模、委託する業務内容で特定し、当該事業者に禁止される行為を（独禁法よりも）具体的に特定して規定する（受領拒否、代金支払遅延、減額、不当返品、買いただき、指定物資等の購入強制など）。
- ただし、違反が認定された場合でも、行われる措置は「勧告」にとどまる（プラス社名公表）。ほとんどは勧告もなく、注意で終わる。

効果重視アプローチの見直し

- 日本のスマホソフト競争促進法（2024年6月制定、2025年12月18日全面施行）も同様。
- 「特定ソフトウエア」（スマホ用OS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン）を以て「一定の取引分野」とし、これらの特定ソフトウエアの事業規模と利用者数によって「特定ソフトウエア事業者」を指定し、5条から9条までの禁止行為を以て「排除」行為としたと考えられる。
- この点では、シャーマン法2条よりも、TFEU102条・市場支配的地位濫用の禁止の形式に近いか（正田、2007）。

効果重視アプローチの見直し

- 以上のように効果重視アプローチ見直しの潮流がみられるとすると、単独行為規制の改正は次のような方向が考えられるのではないか。
  - ①排除行為（と支配行為）を具体的に規定する。
  - ②一定の取引分野ないし市場の画定を極度に複雑化させない。例：二面（多面）市場、フォアーマーケット・アフターマーケットなど。
  - ③競争の実質的制限や公正競争阻害性の立証について現実の反競争的効果の立証を要求しない（potential effectsで足りることを明示する）、あるいは正当化事由や反競争的効果について立証責任の分配を行う。

参考文献

- L. McCallum et al., *A dynamic and workable effects-based approach to abuse of dominance*, Competition policy brief, March 2023
- H. Schweitzer, *The Art to Make Gatekeeper Positions Contestable and the Challenge to Know What is Fair: A Discussion of the Digital Markets Act Proposal*, Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 2021, p.503
- S. Vande Walle, *Civil Litigation and Competition Law- Japan and the EU.,*CPRC/JFTC, 2025
- 黄銘傑「現代化発展に向かう台湾競争法の課題」、土田和博編『独占禁止法とフエアコノミー：公正な経済を支える経済法秩序のあり方』371頁（日本評論社、2017年）
- 栗田誠「排除行為規制の現状と課題」、金井貴嗣ほか編『経済法の現代的課題―舟田正之先生古稀祝賀』175頁（有斐閣、2017年）
- 公正取引特報2003.10（別冊）
- 正田彬「独占禁止法による市場支配力の規制」ジュリスト1327号117頁（2007年）
- 平林英勝「不公正な取引方法の歴史・意義・課題」日本経済法学会年報30号67頁（2009年）
- 裵辰澈「公正取引紛争調停制度について」公正取引798号47頁（2017年）
- 和久井理子「グーグル（アンドロイド）事件（公正取引委員会排除措置命令）」新・判例解説Watch/経済法No.104、2025年
- 土田和博『経済法のルネサンス』292-293頁（課徴金）、329頁以下（民事救済）（日本評論社、2022年）